

《【문제15.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하여 제1심과 항소심에서 모두 승소하였다. 항소심 판결은 2024. 3. 1. 乙에게 송달되었고, 乙은 항소심 판결 중 사실인정에 채증법칙 위반의 잘못이 있고 대여금의 소멸시효가 완성되었음을 주장하며 상고를 제기하고자 한다.

그런데 乙은 상고장 제출 당시 상고이유를 기재하지 않았고, 상고기록 접수통지를 받은 날로부터 20일이 지나도록 상고이유서를 제출하지 않았다. 그 후 乙은 뒤늦게 상고이유서를 제출하면서, 항소심 판결에 관여한 판사 A가 제1심 판결에도 관여하여 민사소송법 제424조 제1항 제1호의 법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 판사가 판결에 관여한 때에 해당한다는 점을 새로이 주장하였다.

또한, 별개의 사건에서 丙은 丁을 상대로 소를 제기하였으나 항소심에서 패소하였다. 丙은 상고심에서 항소심 판결이 이유를 밝히지 아니하거나 이유에 모순이 있는 때에 해당한다며 상고하였다. 그런데 대법원은 심리 중 丙의 상고이유와는 별개로, 이 사건 항소심 재판의 전제가 된 소송대리권의 흠결이나 전속관할 위반 여부 등에 대해 의문을 갖게 되었다.

(물음1) 乙이 상고이유서 제출기한을 도과하여 제출한 상고이유서에 기재된 절대적 상고이유(판결에 관여할 수 없는 법관의 관여)를 상고심 법원이 심리할 수 있는지 여부를 민사소송법 제429조(상고이유서를 내지 아니한 경우의 처분)와 관련하여 논하시오.》

<문제15.2의 물음1> 상고이유서 제출기한 도과 후 제출된 절대적 상고이유의 심리 가능성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙이 항소심 판결에 대하여 상고를 제기하였으나 상고이유서 제출기간을 도과한 후 절대적 상고이유를 주장한 상황이다. 쟁점으로 <상고이유서 미제출 또는 지연제출의 경우에도 절대적 상고이유에 해당하는 사유를 상고심 법원이 직권으로 심리할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 민사소송법 제429조에 따른 상고이유서 제출의무와 절대적 상고이유의 심리 가능성을 논한다.

II. 상고이유서 제출기한과 상고기각

1. 민사소송법 제427조 및 제429조의 규정

(1) 상고이유서 제출기한

- 상고인은 상고장에 상고이유를 적지 아니한 때에는 상고기록 접수통지를 받은 날부터 20일 이내에 상고이유서를 제출하여야 한다. 이 기한은 법정 기간으로서 연장될 수 없는 것이 원칙이다.

(2) 기한 도과의 효과

- 민사소송법 제429조 본문에 의하면 상고인이 위 기간 내에 상고이유서를 제출하지 아니한 때에는 상고심 법원은 결정이 아닌 판결로 상고를 기각하여야 한다. 이는 상고심의 신속한 진행을 위한 제재적 규정이다.

2. 상고기각 판결의 예외

- 민사소송법 제429조 단서에 의하면 상고이유서가 제출되지 않았거나 기한을 넘겼더라도, 상고장에 상고이유가 적혀 있거나 직권으로 조사하여야 할 사유가 있는 경우에는 기한 도과를 이유로 바로 상고를 기각할 수 없다.

III. 절대적 상고이유의 심리 가능성

1. 절대적 상고이유의 의의 및 성격

(1) 의의

- 민사소송법 제424조 제1항 각 호에 규정된 사유들로, 판결에 관여할 수 없는 판사가 판결에 관여한 경우(제1호), 법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 법관이 판결에 관여한 경우 등을 포함한다.

(2) 법적 성격

- 이러한 사유들은 소송절차의 중대한 하자를 구성하며, 당사자의 상고이유 기재 여부와 관계없이 법원이 직권으로 조사하여 판결의 당부를 판단해야 하는 직권조사사항에 해당한다.

2. 제출기한 도과와의 관계

(1) 직권조사사항에 대한 판례의 태도

- 대법원은 상고이유서 제출기간 내에 상고이유서를 제출하지 않았거나, 기간 경과 후에 상고이유서를 제출한 경우라 하더라도, 그 상고이유서에 기재된 내용이 직권조사사항에 해당하거나 절대적 상고이유에 해당하는 경우에는 법원이 이를 심리하여야 한다고 판단한다.

(2) 법리적 근거

- 상고이유서 제출기한을 두는 목적은 상고심의 효율성이지만, 법률에 어긋난 재판이나 중대한 절차적 하자가 있는 판결을 그대로 확정시키는 것은 재판의 적정성과 정의에 반하기 때문이다. 따라서 제429조 단서의 직권으로 조사하여야 할 사유에는 절대적 상고이유가 포함되는 것으로 해석된다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 상고이유 분석

- 乙이 뒤늦게 주장한 사유는 판결에 관여할 수 없는 판사가 판결에 관여한 경우이다. 이는 민사소송법 제424조 제1항 제1호에 해당하는 절대적 상고이유이자 직권조사사항이다.

2. 법원의 심리 의무

- 乙이 상고기록 접수통지를 받은 날로부터 20일을 지나 상고이유서를 제출한 것은 사실이나, 제출된 내용에 중대한 법률 위반인 절대적 상고이유가 포함되어 있다. 민사소송법 제429조 단서에 따라 직권조사사항이 있는 경우에는 기한 도과를 이유로 상고를 기각할 수 없으므로, 상고심 법원은 乙의 상고이유서 제출 시점과 관계없이 해당 사유를 심리하여야 한다.

V. 결론

- 상고이유서 제출기한을 도과하여 제출된 상고이유서라 하더라도, 그 내용이 민사소송법 제424조 제1항의 절대적 상고이유에 해당하는 경우에는 법원이 이를 직권으로 심리하여야 한다. 이는 민사소송법 제429조 단서가 규정한 직권조사사항의 예외에 해당하기 때문이다. 따라서 사안에서 상고심 법

원은 乙이 주장한 법관의 관여 문제를 심리하여 항소심 판결의 위법 여부를 판단하여야 한다.